

1510666-49.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... em pena restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas, no HC 97256. Neste sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIMENTO. DECISÃO BASEADA, APENAS, NA VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 44 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DIREITO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510666-49.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510666-49.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2117103/2021 - 34º D.P. MORUMBI, 17632309 - 34º D.P. MORUMBI, 1174/21/338 - 34º D.P. MORUMBI, 2117103 - 34º D.P. MORUMBI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEIVID OLIVEIRA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

DEIVID OLIVEIRA SILVA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", combinado com artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06 combinados com artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 29 de abril de 2021, por volta das 13h30, na Rua Paulo Bourroul, altura do numeral 100, Morumbi, nesta cidade e comarca da Capital, DEIVID OLIVEIRA SILVA, qualificado a fls. 11, durante a calamidade pública decretada em razão da pandemia causada pelo COVID-19, agindo em concurso com o adolescente Cleverson Souza Da Silva, trazia consigo e mantinha

em depósito, para entrega a terceiros consumidores, 36 (trinta e seis) porções de cocaína, com peso líquido de 15,5g (quinze gramas e cinco decigramas), bem como 36 (trinta e seis) porções de "maconha", com peso líquido de 34,4g (trinta e quatro gramas e quatro decigramas), consoante auto de exibição e apreensão de fls. 09 e laudo de constatação de fls. 26/29 e laudo definitivo de fls. 105/107, drogas causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu constituiu defensora e apresentou defesa prévia (fls. 109/113).

A denúncia foi recebida (fls. 119) e o réu citado.

Na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público sustentou a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

O guarda civil metropolitano Tiago, em juízo, confirmou que estava em apoio de uma diligência da polícia civil, utilizando-se de cães farejadores afim de localizar drogas no local. É condutor do cão farejador. Depois que o local estava seguro, os cães foram soltos para localizar as drogas, as quais foram encontradas embaixo da escada. Tanto o réu quanto o menor foram abordados pelos policiais civis anteriormente. Não teve contato direto com o réu nem com o menor.

Os policiais civis Mário e Leonardo, ouvidos em juízo, relataram que visualizaram dois indivíduos em local já conhecido pela venda de entorpecentes e decidiram fazer a abordagem. O menor de idade estava com uma bolsa pendurada no pescoço. Dentro dessa bolsa, encontraram uma pequena porção de entorpecente. Próximo deles, embaixo de uma escada, encontraram o restante das porções de entorpecentes com a ajuda de um cão farejador. Indagados, o menor de idade e o réu confessaram a traficância no local.

A testemunha de defesa Ingrid disse que não presenciou os fatos. Não sabe de nada que desabona a conduta dele. Nunca viu ele usar drogas. Sabe que ele trabalha.

Interrogado em juízo, o réu confessou a traficância. Disse que fez isso por necessidade financeira. Confirma que o adolescente apenas ficava de olho. Ganhava por dia 120 reais. Era a primeira vez que fazia isso.

Não há razão para que seja invalidada a confissão, se a mesma está em harmonia com as demais provas produzidas.

Constata-se, portanto, que os policiais civis e o guarda civil metropolitano prestaram depoimentos coesos, não tinham inimizade ou conhecimento com o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

A materialidade do delito, por sua vez, está comprovada pelo laudo de fls. 105/107, conclusivo no sentido de que a substância apreendida com o réu era entorpecente.

Quanto ao adolescente, observo que ele demonstrou total discernimento sobre sua ação perante a autoridade policial, soube se defender e não há qualquer prova que indique que o acusado tivesse influência sobre sua conduta ou sobre o fato dele ser usuário e comerciante de droga.

Por fim, não obstante, é de rigor o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II alínea "j", do Código Penal, adotando-se, in casu, as lições Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que, aqui, o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito. " (in Código Penal Comentado, 20ª edição, Editora Forense, 2020, pg. 401).

No caso concreto, embora incontestado o estado de calamidade pública, não se verifica que o acusado tenha se aproveitado dessa situação para a prática do crime ou de que tenham realizado o delito contra vítima de posição de maior vulnerabilidade decorrente da situação de calamidade.

Na aplicação da pena pela acusação do tráfico, levando em consideração as condições do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da lei 11.343/06, considerando a primariedade, é aplicável a pena base no mínimo legal, o que equivale a (05) cinco anos de reclusão e pagamento de (500) quinhentos três dias multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, tendo em vista que a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal nesta fase, nos termos da sumula 231 do STJ. Na terceira fase, considerando que não há indícios de envolvimento do acusado com organização criminosa, reduzo a pena em 2/3, o que corresponde a (01) um ano e (08) oito meses de reclusão e pagamento de (166) cento e sessenta e seis dias multa, pena que se torna definitiva já que não há outras causas a serem apreciadas.

Nos termos dos artigos 49 e 60 do Código Penal, levando em conta a condição econômica declarada pelo réu, fixo o dia multa no seu valor mínimo legal.

Embora o regime deva ser o fechado para cumprimento de pena, em função do disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei Federal nº 8.072/90, observo que neste caso específico dos autos, o acusado é primário e confessou os fatos, de forma que a custódia mais rigorosa não se justifica, sendo, portanto, conferido o regime aberto para início de cumprimento de pena. Poderá recorrer em liberdade em virtude disso.

Por fim, cabe decidir a respeito da substituição da pena privativa de liberdade. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o dispositivo da Lei n. 11.343/06 que proíbe expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas, no HC 97256. Neste sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIMENTO. DECISÃO BASEADA, APENAS, NA VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 44 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DENEGACÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. PENA. REGIME. LEI 8.072/1990. DISPOSITIVO QUE IMPUNHA O REGIME FECHADO PARA CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS.

INCONSTITUCIONALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. I - Não obstante a vedação prevista no art. 44 da Lei 11.343/2006, o Plenário desta Corte, ao apreciar o HC 104.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da proibição de concessão de liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico, por ser incompatível com os princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, entre outros. II - Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, sem prejuízo de que o magistrado de primeiro grau, caso entenda necessário, fixe, de forma fundamentada, uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. III - Concessão da ordem de ofício para determinar ao juízo de piso que: i) superada a obrigatoriedade de imposição do regime fechado aos condenados por tráfico de drogas, avalie se o paciente preenche os requisitos para a fixação do regime aberto, ou, caso entenda pela imposição de regime mais grave do que o previsto para o quantum de pena, que o faça de forma fundamentada, e ii) afastado o óbice à conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, analise se o paciente preenche os requisitos para a referida substituição. (STF. HC 114029-SP. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, j. 18.02.2012, DJe 22.02.2013).

Nota-se que o Superior Tribunal de Justiça admite tal substituição, inclusive o regime aberto de cumprimento de pena, conforme julgados: STJ. HC184497-SP. Relator: Ministro Jorge Mussi, j. 07.02.2013, DJe 19.02.2013; HC 216197-RS. Relator: Ministra Laurita Vaz, j. 07.02.2013, DJe 18.02.2013.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE em parte a presente ação penal, para CONDENAR o réu DEIVID OLIVEIRA SILVA à pena de (01) um ano e (08) oito meses de reclusão, no regime aberto, a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito conforme acima estabelecido, e pagamento de (166) cento e sessenta e seis dias multa, por incorrer nas penas do artigo 33, "caput", e § 4º, da Lei 11.343/06. O réu está absolvido de estar incurso no artigo 40, inciso VI, da lei 11.343/06 com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia. O dinheiro deverá ser depositado ao Senad.

Como já há laudo nos autos, officie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito. Publicada em audiência, intimadas as partes. Registre-se e comunique-se e aguarde-se em cartório prazo para recurso.

São Paulo, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA